

1507722-53.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Robson Silveira Barbosa e Ronaldo Siqueira de Melo, testemunhas de acusação, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pela rua Finlândia, quando observaram um rapaz no meio da praça, conhecido ponto de tráfico de drogas. Ele estava a 10 metros de distancia. O Guarda Robson estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507722-53.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507722-53.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2340547/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21954580 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3535/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2340547 - DEL.POL.SALTO, 3535/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MARCELO DE SOUZA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu PAULO MARCELO DE SOUZA FILHO, como incurso no art.33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 40, incisos inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), da Lei Federal nº 11.343/06 e com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), porque, em tese, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 23h02min, na Rua Finlândia, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 23 (vinte e três) porções de "cocaína", com peso líquido de 8,86g (oito gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 03 de fevereiro 2022 (fls. 57-61).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 73-86).

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022 (fl.101-104).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas cinco testemunhas arroladas pela defesa e duas pela acusação.

A preliminar de nulidade da prisão em flagrante, realizada por guardas municipais, foi rejeitada pela decisão de fls. 101-104.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, a fixação da pena no mínimo legal, diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei Lei 11.343/2006, reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/06. A Defesa, por sua vez, em alegações finais por memoriais, reiterou a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, realizada por guardas municipais. No mérito pugnou pela absolvição por ausência de provas de autoria e elementos caracterizadores do tráfico e, alternativamente, aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal e da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/06, aplicação do redutor previsto no art. 33 § 4º da Lei n.º 11.343/06, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 13), auto de constatação preliminar (fls.12) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 52-54) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Robson Silveira Barbosa e Ronaldo Siqueira de Melo, testemunhas de acusação, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pela rua Finlândia, quando observaram um rapaz no meio da praça, conhecido ponto de trafico de drogas. Ele estava a 10 metros de distancia. O Guarda Robson estava com uma lanterna, de iluminação forte, e em toda perseguição manteve contato com o suspeito. Antes o local foi iluminado pela luz da viatura. Desembarcaram para efetuar a abordagem, o rapaz jogou uma sacola e correu, atravessando um campo de futebol. Em revista pessoal, nada irregular foi localizado, porém, retornando ao local em que ele fora visto, constatou-se que a sacola dispensada continha 23 porções de cocaína e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). O rapaz negou a propriedade das drogas e do dinheiro, afirmando que correu pois ficou com medo de ser abordado. Há uma quadra de areia próxima ao local da abordagem. É possível jogar na quadra à noite, embora a iluminação seja precária. Famílias costumam utilizar o local como lazer durante o dia. No momento da abordagem só havia o réu no local. (íntegra às fls. 168-205)

Rafael Prado da Silva, testemunha de defesa, em Juízo, disse que assinou a declaração de fls. 29 do processo, de forma voluntária. Considera o réu como um irmão e isso não é justo, uma condenação sem provas. Estava jogando bola no campinho de areia da praça junto com o acusado. O local é utilizado para o lazer, mas também é ponto de tráfico. Há abordagem policial com frequência. Por vezes, os policiais encontram entorpecentes e imputam a posse aos que estiverem pelo local, naquele momento. A GCM chegou pela Rua Bolívia, pelo lado que não tinha iluminação, não daria para ver com clareza a área do campinho. Um desconhecido jogou uma sacolinha em sua direção e ele e Paulo correram, com medo. A sacola não estava com Paulo. Só o campinho era iluminado, o restante da praça não tinha iluminação. Havia cerca de cinco pessoas jogando bola pelo local, todos correram. A pessoa que jogou estava na ponta da praça, na Rua Bolívia, de onde chegou a viatura. A pessoa estava a cerca de cem metros deles, jogou a sacola e correu, mas a sacola não caiu próximo deles. Correu para sua casa e Paulo correu para casa dele. Paulo saiu da quadra de areia e foi em direção ao campo. Ele mora na rua Japão. Não viu a abordagem, ficou

sabendo da prisão de Paulo por um amigo. Não é usuário de drogas, Paulo também não. Não conhecia os policiais. (íntegra às fls. 226- 244).

Gustavo Anthony de Almeida, testemunha de defesa, em Juízo, relatou que é amigo do réu, mora próximo à casa dele. No dia dos fatos esteve na praça e viu o réu jogando bola. Tinha dois times jogando bola. Tem bastante tráfico na praça. Há bastante abordagem policial no local. Saiu do trabalho e passou na praça às 10:40h. Depois foi pra casa, retornou à praça por volta de 11h. Não viu a abordagem policial, somente viu o acusado dentro da viatura em frente à casa dele. (íntegra às fls. 206-221).

O réu, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que estavam jogando bola na praça, a ROMU chegou pela Rua Bolívia. Um desconhecido gritou "a ROMU" e jogou uma sacola contendo drogas. Saiu correndo com medo. Nunca tinha visto o desconhecido. Ele saiu da parte de cima praça quando jogou a sacola, direção da Rua Bolívia. A sacola não ficou muito próxima. Os policiais se aproximaram, e o declarante correu, entrou no campo, pulou a grade e os policiais o abordaram na rua. Havia cinco pessoas no local. Todos correram em direções diferentes. Não viu para onde correu o desconhecido que jogou a sacola. Não tem problemas com os policiais que o abordaram. Não é usuário de drogas. Os policiais mentiram, pois não foi sentido a viatura. Quando estava dentro do campo os policiais apontaram a lanterna em sua direção (íntegra às fls. 245-256).

Analisada a prova oral produzida, tem-se que o testemunho de Rafael Prado da Silva deve ser visto com reservas, em razão de amizade íntima, visto que ele afirmou considerar o réu como um irmão.

A testemunha Gustavo Anthony de Almeida não presenciou a abordagem policial, nada esclarecendo de relevante sobre os fatos em análise.

O réu apresentou versão sem amparo em qualquer prova, simplesmente alegando que a droga apreendida pelos guardas era de um desconhecido, não identificável, que fugiu para local ignorado.

De outro lado, os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente no sentido de que o réu estava sozinho na praça e, após aproximação dos agentes de segurança, dispensou uma sacola e fugiu. Depois da abordagem pessoal localizaram a mencionada sacola que continha 23 porções de cocaína. O guarda Robson esclareceu que inicialmente o lugar foi iluminado pela viatura e, durante toda a perseguição, utilizando lanterna de forte iluminação, manteve contato visual com o suspeito, vide transcrição em fls. 169-170.

Note-se que o próprio réu disse não ter problema pessoal com nenhum dos guardas municipais (fls. 248) e confirmou o uso da lanterna (fls. 253), embora alegue que o objeto foi apontado após ele correr.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese.

Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito. Considerando-se ainda que a prisão decorreu de abordagem por fundada suspeita, decorrente do abandono da sacola e fuga do acusado, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, de modo que inexistia óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela.

Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu, que sequer era conhecido nos meios policiais. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da

reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.00000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) APELAÇÃO - tráfico de drogas. Visualização de estar com sacola, procurando se afastar dos policiais e jogando sacola ao chão. Dentro da sacola, a expressiva quantidade de droga apreendida. Desnecessária visualização de ato de comércio: a quantidade e variedade de droga apreendida conduzem à segura conclusão de fim de tráfico, venda no varejo. Jogar fora, se desfazer de algo torna aquilo "res nullius" e sua apreensão não ataca Direito Constitucional de individualidade. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Considero que a posição do Juízo sentenciante deve ser avaliada por ser a pessoa mais próxima quer do apelante, quer da Comarca em que os fatos ocorreram. Com isso, pode melhor avaliar as condições daquele que foi condenado, com a repulsa ou consideração Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, ainda que exacerbada - presença do art. 59, CP e art. 42, L. 11.343/2006. O critério trifásico foi observado em face dos autos, considerada a circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501339-66.2020.8.26.0535; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2021; Data de Registro: 01/10/2021)

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos em praça pública (fls. 88-89), local que além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza". Além disso, o fato foi praticado por volta das 23 horas e não restou demonstrado aglomeração de pessoas. Pelo contrário, os guardas municipais afirmaram que a praça é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas e no momento da abordagem, havia somente o réu no local. Nesse sentido, já julgou o STJ e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO

CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

Por fim, consigna-se que o Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 23 (vinte e três) porções de "cocaína", com peso líquido de 8,86g (oito gramas e oitenta e seis centigramas), o réu é primário (fls. 22-23) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, em grau máximo.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presentes as atenuantes da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu PAULO MARCELO DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade

substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA